

1500923-02.2021.8.26.0297

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... recebido "denúncia anônima" sobre o tráfico por parte do réu. Portanto, é evidente que haviam fundadas suspeitas para ingressarem no imóvel.

Registre-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500923-02.2021.8.26.0297 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500923-02.2021.8.26.0297

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2148641/2021 - 1º Distrito

Policial de Jales, 1823/2021 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA (filho de Sandra Ferreira da Silva, nascido em 01/08/1994, natural de Jales - SP, RG 49756069) foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia 01 de junho de 2021, por volta das 15h, na Rua Professor Luiz Carlos de Oliveira, altura do nº 468, Bairro Big Plaza, neste município de Jales-SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 19,66 gramas de cocaína na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar.

Notificado (p. 205), o réu defendeu-se previamente por intermédio de sua advogada constituída (p. 206/210).

Recebeu-se a denúncia em 06 de outubro de 2021 (p. 222/223).

O réu foi citado pessoalmente (p. 268).

Decretoou-se a prisão preventiva do réu, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas quando da concessão de liberdade provisória

(p. 295/298).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas duas testemunhas de acusação (Vitor Hugo Murari Cardozo e Oleno Carlos Faria Garzella). Por fim, interrogou-se o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a procedência do pedido.

Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo-se em vista a quantidade e a natureza do entorpecente. Rechaçou a incidência da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da LD. Pugnou pela fixação do regime inicial fechado. Por fim, opinou pelo perdimento da quantia (R\$700,00) e do veículo apreendidos, bem como opinou pela restituição dos aparelhos celulares.

Por sua vez, a defesa pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar. Quanto ao mérito, requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente pediu a aplicação da pena no mínimo legal e a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da LD, em patamar máximo (2/3). Ainda, pugnou pela aplicação do regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mais, postulou a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade, além da restituição do veículo, quantia e celulares apreendidos (p. 441/476).

É o relatório.

Afasta-se a preliminar de nulidade da prova obtida nos autos, em razão da ilicitude do meio, ou seja, busca domiciliar na residência do réu Gustavo. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Tema 280 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

(RE nº 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015).

No caso, inviável o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes das buscas realizadas na residência de Gustavo, pois a dinâmica dos fatos não deixa dúvida de que ele foi abordado e preso em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos que ingressaram no imóvel não se mostra ilegal ou ilícita.

Mormente porque os policiais civis lograram êxito em abordá-lo transportando entorpecente logo depois de terem recebido “denúncia anônima” sobre o tráfico por parte do réu. Portanto, é evidente que haviam fundadas suspeitas para ingressarem no imóvel.

Registre-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão.

Por essas razões, não há ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio do réu.

Quanto ao mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) está provada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), pelo boletim de ocorrência (p. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (p. 16/17), pelo laudo de constatação prévia (p. 20/22), pelos boletins “disque denúncia” (p. 23/24), pelo laudo pericial nos objetos apreendidos (p. 146/149), pelo laudo de exame definitivo de entorpecente (p. 150/152) - que atestou que a droga apreendida tratava-se de “cocaína” -, pelo laudo pericial na balança (p. 173/175), bem como pela prova oral. A autoria é certa.

O réu Gustavo, interrogado em juízo, negou a prática do tráfico de drogas. No dia dos fatos machucou o dedo, por isso, foi à casa de “Jide” pedir para ele fazer as entregas do estabelecimento. Quando chegou à casa de “Jide” um policial abordou-o.

O outro policial voltou trazendo uma droga do mato. Negou a propriedade do entorpecente. Permaneceu na residência de "Jide" enquanto outra viatura realizou buscas em sua residência e no seu estabelecimento. Não empreendeu fuga. "Jide" trabalhava na empresa de seu sogro. Não tinha ninguém no "Açaí", porque eram duas horas da tarde. Não arremessou a droga. A droga não lhe pertence. Não é usuário. Confirmou que "Jidláfe" é a pessoa retratada na imagem de p. 220. A balança de precisão foi apreendida em seu estabelecimento. Não pesava entorpecentes nela. Depois dos fatos foi preso em flagrante por outro tráfico. Não acompanhou as diligências em sua residência e nem no estabelecimento. Não sabe dizer o porquê haviam resquícios de drogas na balança. Vitor Hugo e outro policial levaram-no ao UPA. Os policiais forjaram o flagrante, mas não sabe o porquê fizeram isso. Foi abordado pelos policiais militares depois de sair da cadeia, tendo seu veículo revistado em frente ao filho. Não tem nada contra os policiais. Oleno Carlos Faria Garzella, investigador de polícia, recebeu diversas informações de que Gustavo traficava drogas em sistema de "delivery", abastecendo outros traficantes da cidade. No dia dos fatos foram informados que o réu levaria uma porção de drogas no "Big Plaza". Sabiam que Gustavo utilizava-se de uma "Honda/Biz" para entregar as drogas. Viram o momento em que Gustavo passou com a motocicleta pelo bairro. Ao notar a presença da viatura, o réu parou a motocicleta em frente à casa de "Jide", outro traficante conhecido nos meios policiais, e entrou correndo no corredor lateral do imóvel. Foi atrás do réu, tendo visto o momento que ele arremessou algo no terreno vizinho. Indagado, Gustavo negou ter arremessado drogas. Encontrou o entorpecente, enrolado em papel filme, perto de uma cerca. Gustavo negou a propriedade do entorpecente. Foram informados que alguém levava droga no estabelecimento "Açaí" e o réu fracionava para distribuir. Uma equipe policial rumou à residência do réu, tendo localizado setecentos reais em dinheiro. No "Açaí" encontraram um papel filme e uma balança de precisão com resquícios de "crack", conforme atestado em perícia. Quatro meses depois realizou novo flagrante do réu por tráfico de entorpecentes. Foi ao estabelecimento "Açaí", mas não sabe se Vitor Hugo realizou buscas na residência do réu. Os familiares de Gustavo não acompanharam as buscas.

Vitor Hugo Murari, investigador de polícia, disse que a DISE de Jales recebeu diversas informações do envolvimento de Gustavo na prática do tráfico. No dia dos fatos, foi noticiado por "denúncia anônima" que Gustavo entregaria drogas no bairro "Big Plaza". Em companhia do chefe Oleno, deslocaram-se ao local e visualizaram o momento em que Gustavo passou com sua motocicleta "Honda/Biz". Ao notar a presença da viatura, o réu parou o veículo e entrou em uma residência. Perseguiram Gustavo, brevemente, tendo visto o momento em que ele conseguiu se desvencilhar de algo que carregava. Oleno viu Gustavo arremessando algo. Apreenderam dois celulares junto do réu. Encontraram uma porção de vinte gramas de "crack" no lote vizinho. Indagado, o réu permitiu a vistoria no estabelecimento "Açaí" e em sua residência. Encontraram uma balança pequena de precisão e papel plástico no estabelecimento. Não se recordou se a "denúncia anônima" detalhava que a residência da entrega seria a de "Jidláfe". "Jidláfe" era pessoa envolvida no tráfico de drogas. Não se recorda se Gustavo acompanhou as buscas na residência e no estabelecimento.

Como se nota, a versão apresentada pelo réu Gustavo é inverossímil. Embora negue o envolvimento com o tráfico de droga, constata-se, na realidade, que a substância apreendida destinava-se à aquisição por terceiros.

Mormente levando-se em consideração a quantidade de entorpecente apreendida (quase vinte gramas de "crack") – que fracionada resultaria em diversas porções individuais aptas à venda.

Gustavo foi flagrado no momento em que transportava o entorpecente até a residência de "Jidláfe", traficante conhecido nos meios policiais, confirmando a informação recebida pelos policiais de DISE de que ele abasteceria o traficante ("boletim disque denúncia" de p. 24).

Chama atenção, ainda, o fato de ter sido apreendido papel plástico, idêntico à embalagem do entorpecente apreendido, e uma balança de precisão com resquícios de cocaína (laudo pericial de p. 146/149) no estabelecimento comercial do réu.

Além do mais, as testemunhas Oleno e Vitor Hugo, presenciaram Gustavo empreendendo

fuga ao perceber a presença da polícia e viram-no dispensando o entorpecente em um terreno vizinho à residência de "Jidláfe". Declararam que haviam várias "denúncias anônimas" no sentido de que o réu traficava, além de ser pessoa conhecida dos meios policiais pelo envolvimento com drogas.

Ao contrário do suscitado pelo réu em autodefesa, inexistente qualquer elemento de prova a indicar que os policiais quisessem prejudicar Gustavo indevidamente. Principalmente, porque o réu disse que não os conhecia antes dos fatos, bem como que nada tinha contra os servidores públicos.

Logo, é nítida a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo réu.

Assim, diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu Gustavo trazia consigo, para fins de tráfico, 19,66 gramas de cocaína na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. Fato que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

Configurada a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do réu, passa-se a fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias judiciais em seu desfavor. Desse modo, inauguro a pena-base no mínimo legal, fixando a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas. Portanto, mantém-se a pena intermediária no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem sopesadas. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque, o réu é primário e não há provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Registre-se que este juízo vinha levando em consideração a reiteração na prática do tráfico de entorpecentes – ainda que em processamento – para afastar o privilégio legal. Contudo, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento da Quinta e Sexta Turmas – para alinhá-las às decisões do Supremo Tribunal Federal –, no sentido de que "(...) a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal" (HC 664.284/ES, Quinta Turma do STJ, rel. Ministro Riberio Dantas, ocorrido em 21/9/2021, DJe 27/09/2021). Desse modo, diminuo a pena aplicada ao tráfico em 2/3, fixando a pena definitiva em pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, porque a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e o réu é tecnicamente primário. Consigne-se que a equiparação à hediondez do tráfico privilegiado foi afastada por decisões do Superior Tribunal Federal (HC 118.533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016) e do Superior Tribunal de Justiça (Tese Firmada no Tema 600 dos Recursos Repetitivos, publicada em 29/11/2016). Portanto, não deve incidir a determinação do § 1º do artigo de 2º da Lei nº 8.072/90.

Deixo de computar o período de prisão provisória para fins de detração determinado pelo § 2º do art. 387 do CPP, ante a fixação o regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Substituto a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo

33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), o réu não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º): prestação pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA (filho de Sandra Ferreira da Silva, nascido em 01/08/1994, natural de Jales - SP, RG 49756069), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Poderá o condenado recorrer em liberdade, pois o tipo de pena aplicada incompatibiliza-se com a prisão preventiva. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado ao réu Gustavo.

Quanto à quantia (R\$700,00) e objetos (balança de precisão e plástico filme) - constantes do auto de apreensão e exibição de p. 16/17 -, considerando que o condenado não comprovou a origem lícita dos objetos e valor, bem como por guardarem correlação com crime de tráfico de drogas, decreto-lhes o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

No tocante à motocicleta ("HONDA/BIZ 125 ES"), constante do auto de exibição e apreensão de p. 16/17, porque utilizada como instrumento à prática de tráfico de entorpecentes pelo condenado - conforme declarado pelas testemunhas Oleno e Vitor Hugo -, decreto-lhe o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Com relação aos celulares ("Apple" e "Xiaomi"), constantes do auto de exibição e apreensão p. 16/17, não havendo provas de que tenham sido utilizados para prática do crime em análise, autorizo a restituição. Intime-se o réu para retirá-los no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, serão os bens considerados coisa abandonada ("res derelictae"), com destinação dos aparelhos à doação.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Consigne-se que a destruição das drogas apreendidas já foi determinada pela decisão de p. 102/106. Após o trânsito em julgado, deverão ser destruídas as amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos (art. 72 da Lei nº 11.343/06 com a redação dada pela Lei nº 12.961/14).

Com o trânsito em julgado: expeçam-se guias de recolhimento para execução das penas (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); remeta-se ao SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação da quantia e bens declarado perdido em

favor da União, indicando o local em que se encontram e o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente (art. 63, § 4º da Lei nº 11.343/06); e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA